

1002442-72.2020.8.26.0566

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Daniel Felipe Scherer Borborema

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... aos autos do proc. nº 1500291-33.2021.8.26.0569, verifiquei que ele está preso por tráfico de drogas em circunstâncias típicas de quem tem o envolvimento com a traficância em razão de sua vulnerabilidade própria, muitas vezes é usuário habitual ou até mesmo dependente. Isso leva à preocupação de que o valor, levantado de uma única vez, levará a uma vantagem financeira momentânea, com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

Foro de São Carlos

1ª Vara Cível

R. Sorbone, 375, São Carlos - SP - cep 13560-760

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002442-72.2020.8.26.0566 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002442-72.2020.8.26.0566

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Cleiton Donizete dos Santos Barbosa

Requerido:

Rumo Malha Paulista Sa e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniel Felipe Scherer Borborema

Cleiton Donizete dos Santos Barbosa move ação contra Rumo Malha Paulista S/A e Rumo S/A, pedindo a condenação das rés ao pagamento de indenizações por danos morais (R\$ 200.000,00), por danos estéticos (R\$ 200.000,00), pensão mensal vitalícia de 1 salário mínimo considerada a expectativa de vida média do brasileiro, de 76 anos, a ser paga de uma única vez, e, por fim, a arcarem com o tratamento do autor com

consultas, exames, psicólogos ou psicoterapeutas, médico especialista, fisioterapia e medicações, tudo em função de acidente em que envolveu-se em 26/06/2019, quando foi atingido por trem que transitava em linha férrea administrada pelas rés. Contestação às págs. 90 e ss., afirmando-se a ilegitimidade passiva da Rumo S/A e inépcia da inicial, e, quanto ao mérito, ausência de responsabilidade, pois houve culpa exclusiva do autor no evento lesivo; subsidiariamente, afirmam a ausência de incapacidade ou trabalho prévio que justifique a pensão mensal, a ausência de dano estético, a ausência de tratamento por realizar, a ausência de dano moral; mais uma vez a título subsidiário, alegam que as indenizações postuladas são excessivas. Réplica às págs. 158 e ss.

O processo foi saneado com o afastamento das preliminares à pág. 168, e, às págs. 186/184, determinação de perícia de engenharia e perícia médica, cujos laudos aportaram aos autos às págs. 322/343 (engenharia) e 254/261 e 446/451 (médica). Manifestaram-se as partes às págs. 353/356, 363/377, 455/456, e 457/460. Instrução encerrada à pág. 461, as partes apresentaram memoriais finais às págs. 482/508 e 509/519.

É o relatório. Decido.

A Rumo S/A não tem responsabilidade pelo evento lesivo. A linha férrea em que ocorrido o acidente é explorada pela ré Rumo Malha Paulista S/A, o que fica claro a partir do website da Agência Nacional de Transportes Terrestres, vide o endereço <https://portal.antt.gov.br/concessoes-ferroviarias>. O fato de as duas sociedades empresárias integrarem o mesmo grupo econômico não altera a responsabilidade, que é exclusiva da concessionária efetivamente responsável pela administração do trecho em que ocorreu o evento lesivo.

A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos REspS n. 1.172.421/SP e n. 1.210.064/SP, ambos relatados pelo Min. Luís Felipe Salomão e julgados em 8/8/2012, definiu os critérios para o julgamento de ações envolvendo o atropelamento de pedestre em via férrea, sendo eles:

(a) a responsabilidade da concessionária, havendo descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, é uma constante, e alguns exemplos de situações que atraem a responsabilidade são: (1) existência de cercas ao longo da via, mas caracterizadas pela sua vulnerabilidade, insuscetíveis de impedir a abertura de passagens clandestinas, ainda quando existente passarela nas imediações do local do sinistro; (2) a própria inexistência de cercadura ao longo de toda a ferrovia; (3) falta de vigilância constante e de manutenção da incolumidade dos muros destinados à vedação do acesso à linha férrea pelos pedestres; (4) a ausência parcial ou total de sinalização adequada a indicar o perigo representado pelo tráfego das composições;

(b) há concorrência de causas quando: (1) de um lado, a concessionária do transporte ferroviário descumpra o dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea, mormente em locais urbanos e populosos, adotando conduta negligente no tocante às necessárias práticas de cuidado e vigilância tendentes a evitar a ocorrência de sinistros; (2) de outro lado, a vítima adota conduta imprudente, atravessando a via férrea em local inapropriado;

(c) excepcionalmente pode ser reconhecida a culpa exclusiva da vítima, quando cabalmente comprovada.

O caso dos autos é de parcial procedência, reconhecida a culpa concorrente, com maior responsabilidade do autor e menor responsabilidade da concessionária. A responsabilidade da concessionária decorre de que, no local, há vulnerabilidade de segurança nas barreiras físicas entre a linha férrea e a área urbana, o que está comprovado pelos trabalhos periciais, citando-se, de início, o seguinte trecho do laudo de engenharia:

"... Em síntese, o que foi observado no local é que barreiras físicas foram construídas a fim de impedir a passagem de pedestres pela faixa de domínio da ferrovia em locais inadequados e induzir os mesmos a se utilizarem da passagem em nível, mais segura. Porém, verificou-se a existência de danos em trechos das

muretas ... e principalmente nos trechos em cerca, cujo entelamento praticamente não existe mais ..., danos esses que não receberam a manutenção adequada. ..."
(pág. 326).

Com efeito, as fotografias, vg. 2 e 3 (págs. 335, 336), permitem visualizar trecho totalmente aberto entre a passagem de nível a rua paralela, havendo ali o mourão da cerca, mas não os arames ou telas.

Tal fato evidencia a existência de falhas nas barreiras físicas, que agravam o risco de acidentes, atraindo a responsabilidade da concessionária, cabendo citar que a travessia fora da passagem de nível é comum e foi inclusive observada pelo perito, no período em que esteve no local para a vistoria, pág. 327, Quesito 3. O perito deduziu corretamente, aliás, que a manutenção das barreiras físicas é inadequada e parece de fato não ser feita regulamente, pois no intervalo entre o acidente, que ocorreu em 26/06/2019, e a vistoria, feita em 06/10/2020, a situação física do local permaneceu a mesma – pág. 328.

A responsabilidade do autor decorre da acentuada imprudência com que tentou atravessar a linha de trem no caso específico dos autos.

A propósito, o incidente discutido nestes autos é bastante incomum, porque não se trata da situação usual de pedestre que iniciou a travessia da via férrea num momento em que ela estava desimpedida na altura dessa travessia, sendo em seguida o pedestre atingido pelo trem, durante essa travessia.

Bem diferentemente, o que percebemos já no relato do próprio autor, feito no boletim de ocorrência, págs. 36/37, ele, com extrema desatenção, efetivamente iniciou a travessia sem tomar conhecimento de que uma composição férrea já estava passando pelo local, o que chama a atenção de qualquer um que se proponha a entender este acidente.

O autor tinha de estar, de fato, não apenas desatento, e sim extremamente desatento; é forçoso concluir, inclusive, que sequer estava olhando para a frente quando fez a travessia, dadas as dimensões de uma composição férrea. Sem contar, ainda, o barulho do próprio trem que transita a pouquíssimos metros de distância. Como observado pelo perito:

"... para pessoas em condições normais em relação aos seus sentidos (principalmente visão e audição) e sem problemas de locomoção, pode-se afirmar que o local permite perceber com antecedência a aproximação de uma composição férrea. Além disso, acredita-se que a própria vibração e o ruído provocado pela movimentação da composição férrea sejam fatores que facilitem tal percepção."

O que ocorreu é que o autor, segundo afirmado por ele próprio aos médicos, foi atravessar a linha do trem para pegar cocaína para um amigo (págs. 48 e 72), e não viu (!) a composição férrea, sendo 'atropelado de raspão'.

Ainda que tal fato não exclua completamente a responsabilidade da concessionária – e este juiz explicará os motivos mais adiante –, é impossível ignorar que a culpa do autor é muito acentuada na hipótese.

Cumpre explicar a razão pela qual o juízo entendeu que, a despeito da acentuadíssima culpa do autor, na hipótese dos autos há ainda nexos causal entre a falha de segurança da concessionária e o evento lesivo, motivo pelo qual não se exclui, de todo, a responsabilidade desta.

Com efeito, cabe esclarecer que, num primeiro momento, o magistrado cogitou até de afirmar rompido por completo o nexo de causalidade entre a falha de segurança e o evento lesivo.

O raciocínio seria o seguinte: por hipótese, eliminando-se a falha de segurança (juízo hipotético de eliminação, expediente mental e imaginativo indispensável na análise da causalidade), mesmo que o autor, impossibilitado de escolher outro caminho, efetuasse a travessia pela passagem de nível (que, conforme pág. 336 e croquis de pág. 333, está muito perto, a apenas 26,80m da altura do acidente), ainda assim o acidente ocorreria, porque ele continuaria atravessando com desatenção extrema, não percebendo sequer a existência de uma composição férrea trafegando pelo local!

Entretanto, reexaminando essa questão, o juízo observou que a passagem de nível

contém um dispositivo importante de segurança, que justamente assegura uma atenção maior do pedestre, e que impediria – muito provavelmente – o acidente, no caso dos autos.

Tal dispositivo de segurança é o 'zigue-zague' citado pelo perito à pág. 326 e visualizado no croquis de pág. 333 e nas fotografias de págs. 337 e 338, infra. Com efeito, parece claro que para o autor envolver-se neste acidente a sua imprudência consistiu em estar com seus sentidos – especialmente visão e audição – desatentos, sequer olhava em direção à via férrea.

Ora, tal desatenção seria corrigida a partir da exigência imposta pelo zigue-zague, que direciona a atenção do pedestre para a via férrea, caso contrário o pedestre inclusive choca-se contra o próprio muro.

Presente a culpa concorrente, repelindo-se a exclusiva da vítima.

Entretanto, a acentuada desatenção do autor – de iniciar uma travessia enquanto a composição férrea passava à sua frente, bem diante de seus olhos! – tem relevância causal preponderante, de maneira que a sua responsabilidade corresponderá a 65%, neste caso específico, e a da concessionária, 35%.

Ao escrutínio do juiz fica claro que, para que o acidente ocorresse neste caso, e da forma como ocorreu, o autor de fato estava distraído em um grau muito acentuado, quando foi atravessar a linha de trem, motivo pelo qual há maior influência de sua culpa do que da falha de segurança, na causação do evento lesivo.

Cumprir notar que o autor, segundo a prova colhida nos autos, não possuía, à época do acidente, qualquer restrição ou incapacidade de seus sentidos, que justifique não ter percebido a composição férrea.

Firma-se a responsabilidade do autor em 65% e a da concessionária em 35%.

Está configurado o dano moral, que é entendido como o dano extrapatrimonial, isto é, a lesão a interesse não diretamente suscetível de avaliação econômica (GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil.

Responsabilidade Civil. 1ª Ed. Saraiva. São Paulo: 2012. p. 55; DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil. 19ª Ed. Saraiva. São Paulo: 2012. p. 84; GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Responsabilidade Civil. 8ª Ed. Saraiva. São Paulo: 2013. p. 359).

O referido interesse não suscetível de avaliação econômica dirá respeito à própria pessoa do lesado, abrangendo normalmente, segundo JUDITH MARTINS-COSTA (in Dano Moral à Brasileira, RIDB, Ano 3 (2014), nº 2019), um dos seguintes três espectros:

(a) o ser humano biológico: bens jurídicos da vida e saúde, compreendida esta de forma ampla (saúde física, psíquica e emocional), e necessidades vitais (sono, repouso, alimentação, vestuário, etc.); (b) o ser humano moral: bens jurídicos da integridade moral, intimidade, vida privada, identidade e expressão da singularidade pessoal; (c) o ser humano social: bens jurídicos da boa reputação, imagem ou honra objetiva, respeito nas relações profissionais e pessoais, a não discriminação por etnia, opção sexual, religião, educação, etc..

In casu, a saúde física e a emocional do autor foram lesadas, pois ele apresentou trauma na face, fratura em membro superior esquerdo e lesão do nervo radial, ficando inclusive internado (pág. 254), justificando-se, assim, compensação pecuniária.

Quanto ao valor da indenização, a doutrina e a jurisprudência traçaram as principais circunstâncias a serem consideradas para o arbitramento, sendo elas (a) a dignidade ou importância do bem jurídico lesado (b) a intensidade da lesão, isto é, de perturbação ao bem jurídico (c) o grau de culpabilidade do agente causador do dano (d) a eventual culpa concorrente da vítima, como fator que reduz o montante indenizatório (e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Há quem ainda proponha a condição econômica do ofensor, referida na fundamentação de muitos precedentes. Todavia, tal elemento deve ser bem compreendido, à luz das soluções que os precedentes tem apresentado nos inúmeros casos postos à apreciação judicial.

Com efeito, a jurisprudência preocupa-se muito com a questão do enriquecimento indevido, o que serve de argumento contrário à fixação de valores indenizatórios altíssimos com base na robusta condição do ofensor. Temos observado que, na

realidade, a condição econômica é considerada, mas especial e essencialmente nos casos de ofensores de modestas posses ou rendas, para reduzir equitativamente a indenização, evitando a ruína financeira.

Tudo isso levado em conta, no presente caso a indenização seria arbitrada em R\$ 50.000,00, reduzida em 65% em função da acentuada culpa do autor, alcançando assim o patamar de R\$ 17.500,00.

O dano estético exige modificação duradoura ou permanente na aparência externa da pessoa e há de ser uma alteração que tenha um impacto sobre o direito de personalidade que ele visa proteger: o direito à imagem, na perspectiva pessoal (autoimagem) e social (percepção do corpo social), com o foco sobre a harmonia visual, a aparência, a beleza da pessoa.

O STJ define-o como alteração morfológica definitiva sofrida pela vítima, como, por exemplo, a perda de algum membro, uma cicatriz ou outra deformidade corporal, que causa afeição, sequela ostensiva ou permanente, e que seja apta a ensejar repulsa ou, ao menos, desagrado aos olhos de terceiros (REsp 1671613, Rel. Mins. Antonio Carlos Ferreira, j. em 28/08/2017; AREsp 1071118, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. em 01/08/2017; REsp 1388081, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 08/06/2017).

Segundo a doutrina:

"Adentrando-se a qualificação da figura jurídica em apreço [dano estético], tem-se que o dano estético consiste na lesão dos aspectos exteriores de um indivíduo. A imagem e apresentação física da pessoa são alteradas, ocorrendo uma quebra nas características que compõem a sua estrutura corporal. Esses prejuízos são identificados na percepção do próprio lesado, bem como no juízo dos terceiros que compõem o corpo social. Possuem, pois, um duplo viés marcado por subsídios distintos: elemento pessoal e elemento social. Em sentido amplo, poder-se-ia estabelecer como conceito médico-legal de prejuízo estético as consequências das lesões traumáticas sobre uma pessoa, de natureza anatômica ou funcional, que alterem de modo permanente as qualidades materiais da mesma que podem ser percebidas pelos demais e por ele, e que têm efeito sobre seu maior ou menor grau de atração e de aceitação social." (PEREIRA, Fabio Queiroz. Revista de Direito Privado. RDPriv 50/205.Abr.2012).

In casu, o laudo pericial médico citou que o autor apresenta 'cicatriz na face ... de grau residual' (pág. 258), e passou a enfatizar que 'cicatrizes são sempre indelévels, mesmo quando imperceptíveis', e 'deixam marcas emocionais, além das físicas'.

Ora, a narrativa do perito deixa bastante claro que na realidade não estamos, juridicamente, diante de um dano estético, porque este não tem relação com as 'marcas emocionais', havendo necessidade de o dano ser efetivamente estético, tem de haver mudança relevante na aparência, o que não ficou comprovado, motivo pelo qual afasta-se esta indenização.

E dano estético efetivamente não há, tanto que o perito, à pág. 449, Quesito 21, disse: "não há o que se falar em dano estético".

Cumprir notar que o autor poderia ter trazido uma fotografia atual de sua face a fim de mostrar que a cicatriz não é meramente 'residual' como citado pelo perito, tendo deixado de fazê-lo, daí resultando a ausência de prova de qualquer dano estético.

A pensão vitalícia, devida pela depreciação na capacidade do trabalho, é devida ao autor, nos termos do art. 950 do Código Civil, que dispõe, a seu respeito: "Se da ofensa resultar defeito ... pelo qual ... se lhe [do ofendido] diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento ... incluirá pensão correspondente ... da depreciação que ele sofreu".

Havendo redução parcial e permanente na capacidade laborativa, o pensionamento é devido, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em razão do maior sacrifício para a realização do serviço (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp. 636.383/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10.9.2015).

O autor de fato experimentou redução parcial e permanente na capacidade laborativa, à razão de 52,52%, conforme comprovado pela perícia (págs. 446/451).

Na hipótese dos autos, não há comprovação dos rendimentos do autor por ocasião do acidente, de modo que a base de cálculo a adotar deve ser 1 salário mínimo (Superior Tribunal de Justiça, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.821.329/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2ªT, j. 22/4/2020), ou seja, a pensão haveria de ser de 52,5% do salário mínimo.

Todavia, considerando a culpa concorrente e na proporção de 65% e 35% já indicada na sentença, a pensão é reduzida, então, a 18,375% do salário mínimo.

A pretensão de que o pagamento da pensão se dê de uma única vez, no caso dos autos, não deverá ser acolhida. É sabido que essa possibilidade, contemplada no art. 950, parágrafo único do Código Civil, não constitui um direito absoluto da parte, devendo o magistrado avaliar, em cada caso, sobre a conveniência de sua aplicação (Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.987.699/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ªT, j. 2/5/2022).

Na hipótese dos autos, o pagamento ao autor em parcela única seria prejudicial inclusive a ele, consideradas as particularidades do caso. Segundo págs. 48 e 72, o autor seria drogadito, e o próprio evento lesivo teria ocorrido num caso em que ele estaria indo buscar drogas para um amigo. E mais, em consulta aos autos do proc. nº 1500291-33.2021.8.26.0569, verifiquei que ele está preso por tráfico de drogas em circunstâncias típicas de que tem o envolvimento com a traficância em razão de sua vulnerabilidade própria, muitas vezes é usuário habitual ou até mesmo dependente. Isso leva à preocupação de que o valor, levantado de uma única vez, levará a uma vantagem financeira momentânea, com grande risco de ser dilapidado na sequência, colocando-o depois em situação de ainda maior vulnerabilidade, pois teria antecedentes criminais (dificuldade de inserção no mercado de trabalho) e capacidade de trabalho reduzida, sem a renda mensal compensatória que uma pensão lhe proporcionaria.

Por fim, quanto à responsabilidade pelas despesas do autor com seu tratamento, o único que se faz necessário, segundo a prova colhida, é a fisioterapia motora em membro superior esquerdo, conforme quesito 20 de pág. 449.

Tem a ré a responsabilidade de arcar com 35% das despesas com essa fisioterapia, o que haverá de constar da sentença, direito que também está previsto no art. 950 do Código Civil: "Se da ofensa resultar defeito ..., a indenização, além das despesas do tratamento"

Julgo parcialmente procedente a ação e para condenar apenas a ré Rumo Malha Paulista S/A nas seguintes obrigações: (a) pagar R\$ 17.500,00 a título de indenização por danos morais, com atualização pela tabela do TJSP desde a publicação desta sentença, e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento lesivo em 26/06/2019; (b) pagar ao autor pensão mensal vitalícia de 18,375% do salário mínimo, vencendo-se a primeira em 26/07/2019 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, até o óbito do autor, incidindo atualização monetária pela tabela do TJSP desde cada vencimento, e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação em relação às pensões vencidas antes do ato citatório, e desde o vencimento em relação às vencidas posteriormente; (c) em relação à obrigação do item 'b' acima, incluir o autor em folha de pagamento, sem prejuízo da obrigação de pagar quantia relativa às pensões vencidas antes dessa inclusão; (d) reembolsar 35% da quantia desembolsada pelo autor com fisioterapia motora em membro superior esquerdo, mediante prova documental de cada despesa, com atualização monetária e juros moratórios, ambos desde a efetivação de cada despesa pelo autor (não da data do fato: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.021.500/PR).

Tendo em vista a condição econômica e financeira da ré, e o pequeno valor da pensão mensal, tenho que, em princípio, não há necessidade de constituição de capital, admitindo-se, em contrapartida, que a ré seja condenada, como foi, a incluir o autor em folha de pagamento (Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp n. 989.675/RJ, relator Min. Sérgio Kukina, 1ªT, 19/5/2020). Porém, se durante cumprimento de sentença vier demonstrada a necessidade de constituição de capital, essa providência poderá ser determinada.

Considerando a proporção da sucumbência, condeno a ré Rumo Malha Paulista S/A a arcar com 35% da taxa judiciária devida pelo processo, e a pagar ao advogado do autor honorários de 15% sobre a condenação, observando-se que, em relação à pensão

mensal, devem ser incluídas na base de cálculo todas as pensões vencidas até a prolação desta sentença, e, em relação às despesas com tratamento, todas as despesas (incluídas na condenação) efetivadas, assim também, até este pronunciamento judicial.

Condene o autor em 65% das custas processuais, e a pagar honorários em favor da ré Rumo S/A, de 10% sobre o valor atualizado da causa, e a pagar honorários em favor da ré Rumo Malha Paulista S/A, de 15% sobre a diferença entre o que estava sendo postulado e a condenação, observando-se, em todos os casos, a gratuidade da justiça.
P.I.

São Carlos, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA